

1500447-78.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500447-78.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083405/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23875320 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 758/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2083405 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ISAC GONCALVES ANTONIO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI e Art. 35 "caput" todos do(a)

SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

23/06/2022

Réu Preso

Em 23 de junho de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu ISAC GONCALVES ANTONIO e ROBSON GUIMARÃES DE MORAES, bem como os seus Defensores Técnicos, DR. Mateus Soares OAB 283788/SP e DRA. Nathália Alves da Silva OAB 343405/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Eduardo Leopoldo Ambold (GCM) e Ademir José Vicente (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi

realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus ROBSON GUIMARÃES DE MORAES e ISAC GONÇALVES ANTONIO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 25 de março de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, com o envolvimento de uma criança, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 25 de março de 2022, por volta das 18h55, na Rua José Lencione, nº 389, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, com o envolvimento de uma criança, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 8 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,8 gramas, 4 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 26,2 gramas e 57 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 40 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Na prática delitiva, ROBSON permanecia com uma criança no colo, de modo a ludibriar agentes de segurança e se furtar de eventual abordagem. Os acusados traziam consigo algumas porções e mantinham o restante das drogas em depósito numa construção abandonada existente nas proximidades do local da abordagem, de onde retiravam as porções mediante revezamento, conforme a demanda dos usuários que ali compareciam para comprar entorpecentes. Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam informação de um popular dando conta de que ISAC (de camiseta branca e bermuda jeans) e "outro rapaz" (de camiseta vermelha) - que carregava uma criança no colo - estavam vendendo drogas no local dos fatos, ambos fazendo uso de uma casa abandonada, onde armazenavam e iam buscar as porções de entorpecentes efetuando revezamento, para posterior entrega ao consumo de terceiros. De imediato, os Guardas se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, depararam-se com ISAC e com ROBSON (que estava com uma criança no colo), cujas vestes correspondiam àquelas descritas na delação, acompanhados por terceiro posteriormente identificado pelo prenome Gilson. Na ocasião, ao perceberem a aproximação da viatura, os acusados mudaram de comportamento, demonstraram nervosismo e passaram a caminhar pela via pública. Ante a atitude suspeita, os Guardas Civis efetuaram a abordagem e, com ISAC, os Guardas encontraram 2 porções de "maconha", drogas que o denunciado tinha jogado no chão. Ao ser revistado, ROBSON entregou a criança aos cuidados de uma moça que estava passando pelo local e, em seu poder, os Guardas encontraram R\$ 24,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de drogas, bem como 2 porções de cocaína, drogas que ele tinha jogado no chão. Dando continuidade às diligências, os Guardas se deslocaram até a casa abandonada mencionada na delação e, com o auxílio de cão farejador, lograram encontrar 1 aparelho de telefone celular, bem como mais 55 porções de "maconha", 4 porções maiores de "maconha", e 6 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam as denunciados e estavam destinadas ao tráfico ilícito que ambos promoviam no local de forma associada. Os réus foram notificados (fls. 121 e 123) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 150/165). Assim, por decisão proferida no dia 09 de junho de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 180/186). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com os interrogatórios dos réus, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia, enquanto as

Defesas Técnicas, de outro lado, pugnaram pela absolvição dos réus, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 45/57, bem como Certidões a fls. 32/38. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. I - Preliminarmente, afastado a tese defensiva quanto à nulidade do feito decorrente da ilegalidade da prisão/abordagem realizada pelos guardas civis municipais. A operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, distintamente do alegado pelo D. Defensor, os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). A versão do réu Robson de que lhe fora exigido um vídeo sobre sua suposta venda de entorpecentes, não veio amparado num único elemento probatório, bem como não fora apontado pelos agentes de segurança a fim de incriminar o réu. Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. II - DO MÉRITO: Vencidas as questões preliminares, passo ao julgamento da matéria meritória. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o

seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e o adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 139/144) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O acusado ROBSON, em solo policial (fls. 06), afirmou que realmente estava traficando, pois tem uma filha doente, a qual sofre de hidrocefalia, cuja doença afeta toda a coordenação motora dela. Sua filha fica o dia todo acamada e os remédios são caros, por isso precisou vender droga para poder custear o tratamento da sua filha e os alimentos de sua família. Está muito arrependido do seu ato, pois sabe que é errado, mas que fez por estar desempregado e precisava arrumar dinheiro. Em juízo, disse que realmente estava vendendo, mas naquele horário não tinha nada, já estava indo embora. A criança que pegou na casa de sua prima é seu filho. Estava em frente a casa de sua prima pegando seu filho para ir embora, já Isac estava na outra rua e Gilson estava perto do Isac. Conhece Isac de vista. Isac contou para ele, depois que foram presos, que estava ali para comprar droga. Não conhecia esses guardas. Disse para os guardas que estava traficando, mas não naquele momento. Os guardas lhe mostraram uma filmagem. Não sabe a razão dessa denúncia anônima. Não era sua a droga que foi encontrada. Não tinha nada em seu bolso. Trabalha com pintura. Tem três filhos, é casado. Já foi processado. Por sua vez, o réu ISAC, em solo policial (fls. 20), manteve-se silente. Em juízo, disse que é usuário, que foi ao local buscar duas pedras de crack para fumar, mas quando a polícia chegou os vendedores saíram do mato. Estava na esquina e Robson estava mais para cima e o conhece só de vista. É mentira que dispensou substância entorpecente, pois deu vinte reais para comprar o crack e os

vendedores correram quando viu a viatura. Mora no Valinho, e no seu bairro não tem crack, por isso compra na Fundação. Nunca comprou droga de Robson. Viu quando a droga foi encontrada, pois os guardas entraram na casa abandona e depois voltaram com um monte de droga e disseram que era dele. Já conhecia esses guardas, pois já o prenderam e são loucos para forjar droga para eles. Foi preso numa sexta-feira, e tinha vindo de casa. Não estava com bic ou cachimbo pois fuma em lugar escondido. Trabalha de servente, de pintura. Não é casado. Já foi processado. Analisando a autodefesa dos acusados – colhidas com máxima observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – o réu Isac negou por completo, já Robson confessou que traficava naquele dia mas no momento não o fazia, o que torna sua confissão parcial e insuscetível de incidir como atenuante. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Ademir José Vicente, em sede policial (fls. 15/16), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento próximo do local, quando receberam uma “denúncia” anônima de um popular, o qual não quis ser identificado. Essa informação apócrifa dava conta de que um rapaz de camiseta vermelha, o qual estaria carregando uma criança de colo, e um outro rapaz de camiseta branca e bermuda jeans, de nome Isac, estariam praticando comércio ilícito de drogas. Os traficantes, segundo a delação, utilizavam uma casa abandonada para guardar a droga, ou seja, um depósito clandestino, e que ambos revezavam na retirada do entorpecente para a entrega do consumidor final. Assim, se deslocaram até o local citado e avistaram os dois indivíduos mencionado na denúncia, bem como mais um suspeito junto a eles, os quais, ao avistarem a viatura, mudaram de comportamento demonstrando um certo nervosismo e saíram andando. Então, abordaram os suspeitos, sendo tais elementos identificados como ROBSON GUIMARÃES DE MORAES, o que estava carregando uma criança de colo, ISAC GONÇALVES ANTONIO e Gilson dos Santos, todos com fichas criminais. Afirmou que, em revista de ROBSON, ele entregou a criança para uma moça, a qual passava pelo local, dispensando, neste exato momento, dois micro-tubos de cocaína e mais R\$ 24,00 em espécie. Com ISAC, esse dispensou no solo duas porções de maconha, não localizando mais nada com ele. Enquanto que Gilson não aceitou ser revistado, tumultuando e oferecendo resistência na ação policial e empurrando os agentes públicos, bem como gritando para que os outros dois saíssem correndo. Além disso, dizia: sou das antigas já do crime e vocês não vão me revistar (sic), sendo utilizado uma aplicação de força moderada para a sua contenção. Enfatizou que foram com o cão de faro, Tom, até a residência abandonada, a qual foi mencionada na denúncia. Lá o cachorro sinalizou a caixa de padrão de energia, sendo localizado o restante da droga, totalizando 55 porções de maconha, 04 papелotes de maconha (porção maior), 6 micro-tubos de cocaína e um aparelho celular. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro, que tem alto índice de trafico, quando um senhor os relatou que havia dois indivíduos, um deles com uma criança no colo, que pegavam droga no interior de uma residência e descreveu as vestimentas. Foram ao local, Isac dispensou algo no chão e saiu andando, já Robson foi entregar a criança para uma mulher e nisso deixou cair dois pinos de cocaína. Havia um terceiro indivíduo, possivelmente usuário. Colocou o cão farejador para fazer busca no imóvel abandonado e o cachorro apontou o relógio de luz e ali dentro foi encontrado os demais entorpecente que eram idênticos aos dispensados pelo réu. Robson assumiu o trafico, disse que precisava de dinheiro e tinha um filho deficiente. Perguntas da defesa – nunca tinha visto Robson e Isac juntos e já conhecia Isac dos meios policiais. A criança estava com Robson. A denuncia anônima foi feita por um senhor de 40, 50 anos de idade. Ao se aproximarem, Robson mudou o comportamento e além disso tinha as vestimentas e a criança que foram apontados em denuncia. Apenas Gilson se disse usuário. Os réus não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 17/18), corroborou integralmente

a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que no dia dos fatos uma denuncia anônima de um popular, deu a vestimentas de três indivíduos que estariam realizando o trafico e local. Foram até o local apontado, identificaram os indivíduos, um deles (Robson) estava com uma criança. Robson esclareceu que ficava com a criança para disfarçar a pratica criminosa. Com Gilson foi encontrado apenas

dinheiro. Robson assumiu o trafico e disse que estava precisando de dinheiro. Dentro de uma caixa de energia de uma casa abandonada, foram encontrados mais entorpecentes, idênticos aos que estavam em poder dos réus. Havia uma parente próxima ao local dos fatos, que segurou as crianças. Na denuncia falava que um dos indivíduos estava com a criança no colo. Perguntas da defesa - a denuncia foi diretamente para eles da guarnição. A casa fica uns 50 metros do local em que os réus foram abordados. Havia outras pessoas na rua, mas o que levou a concluir que a droga era deles era porque a droga encontrada era idêntica as que estavam com os réus e também porque a denuncia anônima descreu as vestimentas do réu. A casa era abandonada e a caixa de luz estava do lado de dentro. Nenhum dos réus se disse usuário e Robson assumiu a mercancia enquanto Isac negou. Gilson também foi conduzida à delegacia. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas onde os acusados ROBSON e ISAC as dispensaram, bem como o restante ocultadas próximas de onde estavam; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 139/144), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a conduta dos acusados, os quais, ao avistarem a viatura, apresentaram comportamento suspeito; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas e 5) a localização dos acusados com as mesmas características dos traficantes delatados, inclusive estavam no mesmo local e atuavam exatamente como o denunciado anonimamente. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª

Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 139/144) e demonstrado que os réus incorreram em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Finalmente, conforme prova oral produzida ROBSON realizava a mercancia de drogas com uma criança em seu colo para disfarçar a prática ilícita realizada pelos réus. Com isso, os acusados inseriram a criança no universo da traficância, o que atrai a incidência da causa de aumento especial de que trata o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. III - DA DOSIMETRIA DA PENA: Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da

culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. a) Do Réu ISAC: Observando às diretrizes específicas do art. 42 da Lei de Drogas e as gerais dispostas no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis ao réu. De fato, observo que os apontamentos criminais retratados a fls. 32/35 (Proc. nº 1500697-53.2018.8.26.0571, fls. 34), se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: "embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo, fixo sua pena-base no mínimo legal, isso é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Proc. nº 1500697-53.2018.8.26.0571, fls. 34), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Finalmente, considerando que o crime foi praticado com o envolvimento adolescente, tem-se por necessária a incidência da causa de aumento de que trata o art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. E, portanto, aumento sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torna definitiva, à míngua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência, que, aliás, é específica, do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta

benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). b) Do Réu ROBSON: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, deve-se ser considerado nesse momento que o réu ostenta condenação criminal definitiva com decurso do prazo depurador de reincidência (proc. 0002343-28.2009.8.26.0624 - fls. 37), o que é elemento apto a gerar maus antecedentes. Por tal razão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é de rigor, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, faz-se presente a circunstância agravante de reincidência (fls. 36 - P nº 0005418-34.2013.8.26.0269; e Proc. 0001180-66.2016.8.26.0624 - fls. 36/37), exaspero sua pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis)anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública, como retro exposto. Em terceira fase, existente a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento sua pena na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se trata de réu multireincidente, de maus antecedentes, revelando que, obviamente, se dedica a atividades criminosas, não estando, assim, preenchidos todos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da benesse. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência, que, aliás, é específica, do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). IV - DO DISPOSITIVO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1)condenar o réu ISAC GONÇALVES ANTONIO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; 2) condenar o réu ROBSON GUIMARÃES DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 3) absolver os acusados da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade aos réus, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar deles. E mais, considerando a reincidência de ambos, bem como a evidente persistência de ambos na seara criminoso, inegável que, acaso soltos, tornarão a delinquir, motivo pelo qual a prisão preventiva deles é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomendem-se os réus na

prisão em que se encontram recolhidos. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, posto que ambos foram assistidos por Defensores Dativos (fls. 133/134). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 109) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 24,00 em dinheiro - fls. 147) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP." Pelos Defensores dos réus e pelos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se as competentes certidões de honorários (fls. 133/134). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA